

1502500-74.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL MORITA KAYO

Comarca: Bertioga

Foro: Foro de Bertioga

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 22/02/2022

... que foi surpreendido o réu, em ponto conhecido de tráfico, não se mostram compatíveis com destinação outra que não o comércio ilícito, de que claramente proveniente o dinheiro apreendido, o que afasta qualquer tese absolutória ou desclassificatória.

Assim, autoria e materialidade comprovadas em relação ao crime de tráfico de drogas, passo à dosimetria das penas, atento ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bertioga

Foro de Bertioga

1ª Vara

Av. Anchieta, 162 / 192, Bertioga-SP - cep 11250-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502500-74.2021.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502500-74.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2203598/2021 - DEL.POL.BERTIOGA, 19295842 - DEL.POL.BERTIOGA, 1797/21/204 - DEL.POL.BERTIOGA, 2203598 -

DEL.POL.BERTIOGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GILDO BRANDAO DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL MORITA KAYO

Vistos.

GILDO BRANDAO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a inicial acusatória, no dia 28 de julho de 2021, às 17h46m, na Rua Aprovada, 221, 611 - Jardim Vista Linda, nesta cidade e comarca de Bertioga, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 93 (noventa e três) tubos de eppendorf contendo cocaína, com peso bruto de 120g (cento e vinte gramas), conforme auto de exibição e apreensão de fl. 11, laudo de constatação provisória de fl. 10 e fotografia de fl. 09. O réu foi preso em flagrante delito (fl. 04), sendo sua prisão convertida em

preventiva pela decisão de fls. 54/57.

Notificado (fl. 95), o acusado apresentou defesa preliminar às fls. 101/105.

Recebida a denúncia em 24 de setembro de 2021, com a designação de audiência de instrução e julgamento (fls. 121/123).

Durante a fase processual, foi ouvida uma testemunha, procedendo-se, ao final, ao interrogatório do réu.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais orais, pugnando pela condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia.

Já a Defesa, em memoriais escritos (fls. 178/185), alegou, preliminarmente, a nulidade processual por quebra da cadeia de custódia da prova, uma vez que divergente a quantidade da droga mencionada no auto de exibição/apreensão (fls. 14) e aquela apontada no laudo toxicológico definitivo (fls. 142/144). No mérito, pugnou pela absolvição do réu por insuficiência de provas, formulando pedidos subsidiários.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De proêmio, rejeito a preliminar de nulidade processual por quebra da cadeia de custódia da prova.

Com efeito, estabelece o art. 158-A, "caput", do Código de Processo Penal:

Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

Nas lições de Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto, a cadeia de custódia consiste, em suma, na "sistematização de procedimentos que objetivam a preservação do valor probatório da prova pericial caracterizada, mais precisamente, da sua autenticidade. Cuida dos métodos científicos atuais de manejo da marca vinculada a uma conduta supostamente ilícita. Assegura a preservação dos vestígios desde o contato primário até o descarte dos elementos coletados, garantindo-se a sua qualidade através da documentação cronológica dos atos executados em observância às normas técnicas previstas nas etapas da chamada cadeia de custódia" (Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos 5ª ed. Salvador: JusPodivm, 2021, p. 542).

No caso em tela, o auto de exibição/apreensão de fls. 14 indicou que foram apreendidos "93 (noventa e três) tubos de eppendorf contendo pó branco que o laudo de constatação indicou ser cocaína, com peso bruto de 120g (cento e vinte gramas), acondicionado em saco com lacre nº 4191165".

Ora, o Exame Químico-Toxicológico Definitivo (fls. 142/144) mencionou expressamente que todo o material recebido para análise encontrava-se acondicionado em invólucro plástico lacrado sob o nº 4191165, não se vislumbrando qualquer violação no manejo da prova coletada, que pudesse por em dúvida a sua autenticidade.

Além disso, a divergência entre as quantias apontadas, provavelmente, decorreu do fato de que, no auto de exibição/apreensão, houve a aferição do peso bruto do entorpecente apreendido, ao passo que no laudo definitivo a pesagem se deu pela massa líquida da droga, não se podendo extrair qualquer nulidade processual decorrente dessa diferença.

Bem se vê, portanto, que todo o mecanismo formal para a identificação do objeto da prova, bem como para sua conservação e análise, a fim de se extrair dele os elementos de convicção necessários para a apuração do fato delituoso, foi devidamente observado na presente situação, não se vislumbrando qualquer irregularidade no procedimento administrativo adotado que pudesse macular a prova produzida.

Assim, rejeitada a preliminar e presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais, passo à análise do mérito da causa.

E adianto que a ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (fl. 04), no boletim de ocorrência (fls. 09/11), no auto de exibição/apreensão (fl. 14), no auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fl. 13), na foto

de fl. 12, no laudo de exame químico toxicológico (fls. 142/144), bem como na prova oral coligida.

A autoria, igualmente, é certa e recai sobre o acusado, consoante o vasto acervo probatório produzido em juízo.

A testemunha LUIS AUGUSTO DA SILVA, policial militar, ratificando sua versão apresentada na fase investigativa (fls. 05), disse que chegaram ao local dos fatos, já conhecido como ponto de tráfico de drogas. De longe, puderam ver três indivíduos pulando uma cerca, invadindo uma residência. Todavia, um dos sujeitos não conseguiu transpor a cerca. E, ao notar a aproximação policial, esse indivíduo largou uma bolsinha preta. Esse suspeito era o réu GILDO, que havia sido preso menos de dois dias antes também por tráfico de drogas. No interior da bolsa havia quase cem pinos de cocaína e duzentos reais em dinheiro. A cerca possuía em torno de 1,5m de altura, mas em cima havia arame farpado, o que causou inclusive alguns ferimentos leves no acusado. Indagado informalmente, o réu negou a prática da traficância. O réu GILDO BRANDAO DE OLIVEIRA, em seu interrogatório judicial, cientificado de seu direito de permanecer em silêncio, negou os fatos lhe imputados. Disse que estava voltando de sua casa, pois havia sido preso menos de 24 horas antes pelos mesmos policiais que o prenderam. Como havia brigado com sua esposa, tinha ido pegar suas roupas no local dos fatos. Nisso, viu a aproximação da viatura policial e dois indivíduos fugindo por cima da cerca. Como não estava fazendo nada de errado, permaneceu no local. Foi abordado pelos policiais, mas nada de ilícito foi encontrado consigo. Porém, os policiais foram até a cerca por onde aqueles dois indivíduos fugiram. Dali, os policiais trouxeram uma bolsa dizendo que era do réu. Negou ter fugido dos policiais. Não conhecia os rapazes que fugiram com a chegada dos policiais. Alegou que foi preso por perseguição dos policiais, pois não pratica mais o tráfico de entorpecentes. O local dos fatos é próximo à residência da tia de sua esposa.

Pois bem.

Da análise do manancial probatório contido nos autos, tem-se que a procedência da pretensão acusatória é medida que se impõe.

Com efeito, o depoimento harmônico e coerente dos policiais, tanto na fase investigativa quanto em juízo, aliados aos demais elementos de convicção acostados ao feito, são uníssomos a apontar a autoria do delito por parte do acusado.

Nesse ponto, cumpre destacar que o depoimento de policiais tem valor jurídico idêntico ao de outras testemunhas estranhas aos quadros da polícia, sendo totalmente descabido e inconsequente o preconceito acerca dos seus depoimentos. Na verdade, inexistente qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos judiciais que sejam prestados por policiais. A circunstância de serem agentes públicos não os torna suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo antecipado e genérico sobre o depoimento, de sorte a reduzir-lhe, "a priori", o poder de convencimento.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de afirmar que "o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever do ofício, de repressão geral. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF, HC nº 73.518 - SP, Rel. Ministro Celso de Mello).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento do STJ: "A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não

ocorreu no presente caso" (HC 485543 / SP, Relator(a) Ministro FELIX FISCHER, Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento 21/05/2019, Data da Publicação/Fonte DJe 27/05/2019).

No caso vertente, não se entrevê motivo para que os policiais fossem acusar falsamente o réu. Registre-se que os relatos prestados pelos agentes públicos, em ambas as fases da persecução penal, em seus aspectos principais, são harmônicos, o que lhes confere maior densidade probatória. De resto, pequenas divergências não se prestam a abalar a credibilidade das testemunhas, devendo ser debitadas ao fator tempo, associado à grande quantidade de ocorrências atendidas pelos policiais.

Além disso, a narrativa apresentada pelos agentes públicos encontra plena consonância com o conjunto probatório produzido durante a instrução, corroborando os elementos informativos colhidos na esfera administrativa.

Por outro lado, a versão do acusado revelou-se isolada e inverossímil.

A uma, porque o policial LUIS foi enfático ao afirmar ter visto o réu dispensando a bolsa contendo os entorpecentes, depois que ele não conseguiu pular uma cerca para se evadir do local em razão da aproximação dos policiais.

A duas, pois nada há nos autos que possa desabonar a credibilidade dos relatos dos agentes públicos, inexistindo qualquer indício de que os policiais tivessem algum interesse na condenação de um inocente, ainda que já conhecessem o acusado de abordagem anterior.

A três, porquanto o acusado não trouxe qualquer informação concreta acerca dos demais indivíduos que seriam os proprietários das drogas e que teriam conseguido fugir, antes da abordagem policial, revelando-se genérica e frágil a tese defensiva de que o réu se encontrava no local apenas para pegar suas roupas.

Por fim, urge destacar que o réu já fora processado e condenado anteriormente pela prática do crime de tráfico de drogas, consoante se depreende das certidões de fls. 26/27, tendo inclusive sido preso em flagrante, dias antes, na mesma região, também acusado da prática da mercancia ilícita, o que condiz com a tese acusatória descrita na denúncia.

Assim, longe de ser precária, a prova dos autos é uniforme em incriminar o réu, encontrando amplo amparo em todos os elementos de convicção contidos no processo. Cumpre enfatizar, outrossim, que o fato de o réu alegar ser usuário de substância entorpecente não o exonera da responsabilidade pela prática do delito descrito na denúncia, sobretudo porque a realização da mercancia ilícita pode se dar exatamente para garantir o próprio uso ou vício.

De mais a mais, não se olvide que a condenação pelo tráfico de drogas não reclama a identificação do fornecedor ou do comprador, nem mesmo se exige a prova da efetiva ocorrência do ato de mercancia, tratando-se de tipo misto alternativo.

A propósito, o delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 não possui elemento subjetivo do tipo ou o chamado dolo específico, pois este "aparece apenas no art. 28, de forma que, sendo exclusivamente o porte, a guarda ou a compra, para consumo pessoal, é determinada a aplicação de penas restritivas de direito especialmente previstas em lei. Qualquer outra finalidade do agente determina a incidência do art. 33, inclusive a distribuição gratuita" (VICENTE GRECO FILHO, Tóxicos, Prevenção e Repressão, Saraiva, 13ª edição, págs. 150/151).

Em outras palavras, o crime de tráfico de drogas, tal como concebido na legislação brasileira, não pressupõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização (STF, HC nº 69.806, rel. Min. Celso de Mello; STJ, REsp nº 1.133.943, rel. Min. Felix Fischer). Nesse diapasão, já se decidiu que "a apreensão de grande quantidade de drogas configura o animus de traficar, somente ilidível quando alegada a finalidade exclusiva de uso próprio, com robusto material probatório favorável ao mesmo" (STJ, Rec. Esp. nº 163.640, rel. Min. Jorge Scartezzini, apud Alberto Silva Franco e outros, Leis Penais Especiais e sua Interpretação Jurisprudencial, RT, vol. 2, 7ª edição, pág. 3190).

No mais, acerca da alegada insuficiência de provas para amparar o decreto condenatório, é possível acrescentar a jurisprudência do STJ: "Indicando a Corte local dar-se a condenação não apenas pelo depoimento de policial, mas por outras provas também valoradas, não cabe a pretensão de nulidade da condenação.

Inexistindo impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas

que sustentem a condenação, não há falar em nulidade. 3. Agravo regimental improvido" (AgRg nos EDcl no HC 446151 / RS, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA, Data do Julgamento 07/02/2019, Data da Publicação/Fonte DJe 27/02/2019).

Logo, a quantidade e o modo de disposição das drogas, bem como as circunstâncias em que foi surpreendido o réu, em ponto conhecido de tráfico, não se mostram compatíveis com destinação outra que não o comércio ilícito, de que claramente proveniente o dinheiro apreendido, o que afasta qualquer tese absolutória ou desclassificatória.

Assim, autoria e materialidade comprovadas em relação ao crime de tráfico de drogas, passo à dosimetria das penas, atento ao sistema trifásico previsto pelo artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase, segundo os critérios do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, observo que a natureza e a quantidade das drogas – 93 (noventa e três) tubos de eppendorf contendo cocaína, com peso bruto de 120g (cento e vinte gramas) – são desfavoráveis, uma vez que os entorpecentes em questão são extremamente nocivos, com elevado caráter viciante e destrutivo, tendo sido apreendidos em quantidade considerável. Quanto às demais circunstâncias do art. 59 do CP, verifico que a culpabilidade, consistente no grau de reprovabilidade da conduta, é normal ao caso. O réu possui condenação anterior configuradora de reincidência, consoante se verifica nas certidões e F.A. de 26/27 e 28/35, a ser considerada somente na etapa seguinte, sob pena de "bis in idem". Inexistem elementos para valorar negativamente a conduta social ou a personalidade da sentenciada. O motivo da conduta não é especialmente censurável. As circunstâncias foram inerentes ao delito, já tendo sido sopesadas pelo legislador. As consequências não extrapolaram o comum à espécie. Por se tratar de crime vago, não há se falar em comportamento da vítima.

Assim, presente uma circunstância judicial desfavorável preponderante, elevo a pena base para 6 anos de reclusão, além de 600 dias-multa.

Na etapa intermediária, verifico a agravante da reincidência, conforme certidões e F.A. de fls. 26/27 e 28/35. Assim, elevo a pena provisória para 7 (sete) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, entendo incabível a aplicação do disposto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois, ao instituir a referida causa de diminuição da pena, o legislador objetivou beneficiar o agente que pela primeira vez se lança no mundo criminoso, e cuja conduta não representa um maior perigo para a coletividade, de sorte que a pena reduzida seria suficiente para a ressocialização e reprovação do comportamento. No caso em tela, contudo, o réu é reincidente, consoante certidões e F.A. de fls. 26/27 e 28/35, o que afasta o cabimento da referida benesse.

Desse modo, torno definitiva a pena de 7 (sete) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Arbitro cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo nacional à época dos fatos, devidamente corrigido, uma vez que não há nos autos informações que permitam fixação em outro valor.

Considerando a quantia de pena aplicada, bem como a reincidência do agente, fixo o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, do CP.

Inviável qualquer apreciação sobre detração penal (CPP, art. 387, § 2º), por se tratar de matéria de execução, na forma do art. 66, inciso III, alínea "c" da Lei de Execução Penal, não havendo elementos nos autos suficientes para análise da matéria neste momento.

Incabível a substituição por pena restritiva de direitos (art. 44 do CP), bem como a suspensão condicional da reprimenda (art. 77 do CP), diante do patamar da pena aplicada e da reincidência em crime doloso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória contida na denúncia para CONDENAR o réu GILDO BRANDAO DE OLIVEIRA, já qualificado, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, estabelecido estes no mínimo

legal.

Por se tratar de crime vago, é descabida a fixação de valor mínimo de indenização à vítima, na forma do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

O acusado respondeu ao processo preso preventivamente e não sobrevieram novos fatos ou elementos que pudessem, na forma do art. 316 do Código de Processo Penal, modificar esta situação, especialmente em virtude da gravidade concreta do delito e do fato do réu já ter sido condenado anteriormente pela prática de crime, o que afasta a possibilidade de concessão de liberdade provisória, pois insuficientes outras medidas diversas da segregação cautelar. Portanto, deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Anote-se a publicação da presente sentença como termo inicial para eventual nova reapreciação da necessidade da prisão preventiva, devendo os presentes autos virem conclusos ao Magistrado com competência funcional sobre o processo (Juiz de Direito ou Desembargador Relator, a depender da fase em que se encontrar) no 85º dia a partir desta data, na forma do Comunicado n. 78/2020 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo.

Autorizo a destruição da droga apreendida. Oficie-se, servindo esta sentença, com cópia do auto de apreensão, como ofício.

Custas pelo condenado, ressalvada a gratuidade concedida.

Transitada em julgado, adotem-se as seguintes providências:

- a) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para o pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à cobrança;
- b) expeça-se mandado de prisão e, verificado seu cumprimento, expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento;
- c) proceda-se à transferência do dinheiro apreendido à fl. 14 ao Funad, decretado seu perdimento em favor da União;
- d) comuniquem-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ);
- e) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Arbitro honorários ao patrono nomeado para o réu conforme o valor da tabela do convênio DPE/OAB. Após a certificação do trânsito em julgado, expeça a z. Serventia Judicial a respectiva certidão.

P.I.C.

Bertioga, 22 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA